

1501000-68.2021.8.26.0472

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA

Comarca: Porto Ferreira

Foro: Foro de Porto Ferreira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DHIEGO DA SILVA DOS SANTOS

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de DHIEGO DA SILVA DOS SANTOS, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal e no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em concurso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Ferreira

Foro de Porto Ferreira

2ª Vara

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 525, . - Centro

CEP: 13660-017 - Porto Ferreira - SP

Telefone: (19) 3581-2201 - E-mail: portoferr2@tjsp.jus.br

1501000-68.2021.8.26.0472 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501000-68.2021.8.26.0472

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DHIEGO DA SILVA DOS SANTOS

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de DHIEGO DA SILVA DOS SANTOS, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal e no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em concurso material de infrações, afirmando que em data incerta, porém entre os dias 04 e 10 de agosto de 2021, por volta de 21h10min, na rua Fernando Passini, nº 164, nesta cidade e comarca de Porto Ferreira, recebeu e ocultou na residência onde morava, a motocicleta Honda/CG 125 Fan, ano 2008/2008, cor cinza, placa DNV-8790, pertencente a Willian Roberto da Silva; bem como, no dia 10 de agosto de 2021, por volta das 18h00min, no mesmo local acima, tinha em depósito, 58 porções de "cocaína" com peso líquido de 18,55 gramas.

Segundo se apurou no inquérito policial que embasou a denúncia, "a motocicleta acima descrita foi roubada da vítima Willian Roberto da Silva no dia 04 de agosto

de 2021, por volta de 21h10, nesta cidade de Porto Ferreira, tendo o fato sido comunicado no BO nº 1032/21, às fls. 89/91. Posteriormente, em circunstâncias não devidamente esclarecidas por ele (fl. 06), o denunciado recebeu o veículo acima descrito, sabendo que se tratava de produto de crime e passou a ocultá-lo na residência onde morava, que pertence ao seu genitor José Francisco dos Santos. Todavia, ao tomar conhecimento que um veículo de origem ilícita estava sendo ocultado na residência de sua propriedade, o genitor de DHIEGO acionou a Polícia Militar, comunicando-a do ocorrido e pedindo que fosse até o local averiguar, tendo a guarnição então se deslocado ao endereço apontado (cf. confirmado por José Francisco dos Santos, genitor do denunciado, em audiência de custódia realizada, com link à fl. 70). Ante a autorização dada pelo proprietário da residência, qual seja, o genitor do denunciado, a fundada razão da prática delitiva em questão diante da denúncia de um familiar próximo e a necessidade urgente de se fazer a apreensão, pois tratando-se de bem de fácil mobilidade - veículo de duas rodas - seria rápida e facilmente ocultado em outro local, especialmente após o descontentamento externado e denúncia feita pelo próprio pai do increpado, a equipe policial ingressou no imóvel e lá localizou a motocicleta produto de roubo, tendo DHIEGO afirmado que o veículo havia sido deixado no local pela pessoa apontada apenas como "Silvio". Ainda no interior na casa, sobre a pia da área externa, os policiais prontamente avistaram uma pochete contendo as 58 porções de "cocaína" acima mencionadas, todas fracionadas e prontas para serem comercializadas, fazendo-se necessária a apreensão diante da visualização da substância ilícita. Por fim, o denunciado apontou onde a pessoa que havia deixado a motocicleta poderia ser encontrada e, neste local, foram apreendidas a chave do veículo, a quantia de R\$ 252,85 em dinheiro, algumas bijuterias, um celular Samsung J5, também roubado da vítima Willian e um caderno contendo anotações de tráfico, não sendo, contudo, identificada a pessoa por ele indicada apontada como responsável por tais bens, qual seja, o indigitado "Silvio" (cf. Auto de exibição e apreensão de fls. 18/20 e relatório policial de fls. 123/135). A proximidade entre a data do roubo e da apreensão da motocicleta, a incapacidade do denunciado em apresentar informações verossímeis acerca do veículo, a versão do próprio genitor dele, apontando que já sabia que o filho ocultava um veículo ilícito, o que motivou seu pedido de averiguação pela Polícia Militar e a localização em meio a outros objetos ilícitos ou relacionados à práticas criminosas evidenciam que DHIEGO tinha conhecimento de que se tratava de produto de crime. Por fim, a quantidade e forma de acondicionamento das drogas, a relação do denunciado com as pessoas apontadas e objetos apreendidos ligados ao tráfico (cf. relatório policial de fls. 123/135), seu histórico de envolvimento com tal crime (cf. certidão de fls. 44/45), reforçado pela palavras de seu próprio genitor, além da inverossímil versão de que todas as porções se destinavam a seu uso, demonstram, com segurança, que o denunciado tinha em depósito os entorpecentes com a finalidade de tráfico."

A pessoa imputada foi presa em flagrante (fls. 01/41).

Em decisão de fls. 55/57 o flagrante foi relaxado.

O representante do Ministério Público ofereceu a citada denúncia às fls. 148/151.

A denúncia não foi recebida por decisão de fls. 152/160 a qual considerou que as provas elencadas pela acusação tinham origem ilícita.

O representante Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito às fls. 169/173.

O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso ministerial em acórdão de fls. 239/248 determinando o recebimento da denúncia.

Foi apresentada defesa prévia às fls. 351/353 após a citação de fls. 338.

Foi realizada audiência de instrução com apresentação de alegações finais pelas partes.

Quanto ao estado de liberdade, o Tribunal de Justiça determinou, por acórdão de fls. 86/93 dos autos apensos 0001208-29.2021.8.26.0472, a prisão da pessoa imputada.

O mandado foi expedido às fls. 269 dos presentes autos.

Às fls. 320/323 consta decisão do Superior Tribunal de Justiça concedendo a liberdade à pessoa imputada, sendo expedido contramandado de prisão às fls. 330.

É o breve relatório.
Fundamento e decido.

Com a devida vênia ao respeitável acórdão, transcorrida a instrução, é o caso de concluir pela absolvição em razão da ilicitude da prova colhida.

A decisão que relaxou o flagrante ficou assim fundamentada:

O próprio Ministério Público entendeu pela ilegalidade da prisão em flagrante diante do consentimento dado somente pelo pai de Dhiego, quando, em verdade, este era o verdadeiro morador.

A presença de denúncia identificada a respeito da ocorrência de delito permanente constitui, em meu sentir, "fundadas razões" (nos termos do Tema 280 da Repercussão Geral do STF) para ingresso dos policiais em domicílio. Não vejo, todavia, um outro elemento que tem sido ressaltado pela jurisprudência do STJ como essencial à validade de diligências invasivas, qual seja, a situação de urgência a tornar não recomendável a espera por um mandado judicial.

Não havia qualquer elemento a indicar a possibilidade de sumiço dos objetos que constituíam prova da existência e autoria do delito.

A situação se torna mais grave porque a diligência foi feita por policiais militares, os quais são incumbidos do trabalho de polícia ostensiva, não de polícia investigativa.

Aliás, abordagens açodadas como esta, dificultam posteriormente linhas de investigação que poderiam levar até mesmo a solucionar o crime antecedente à receptação.

De qualquer forma, o ingresso em domicílio foi feito ao arrepio da lei e dos limites constitucionais impostos às forças de segurança.

Ademais, ainda que se considere o ingresso inicial válido, após o encontro da moto indicada pelo informante identificado, não poderiam os policiais continuar a revistar o domicílio, a menos que declinassem "fundadas razões" para tal. Aliás, mesmo quando autorizados por mandado judicial, uma vez encontrado o objeto-alvo, como se depreende dos §§6º e 7º do art. 245 do Código de Processo Penal, cabe aos executores da medida fazer a apreensão e lavrar o auto circunstanciado, interrompendo, por óbvio, as buscas.

A razão disso é evidente.

Ainda que legítima a busca, ela não suspende os direitos do investigado, apenas abre uma exceção, justificada, no tempo e no espaço, circunscrita a uma finalidade prévia. De resto, o direito à inviolabilidade de domicílio continua valendo integralmente. O ingresso na casa de investigado mediante autorização judicial ou mediante fundadas razões do cometimento de crime não é permissivo para devassa na vida do investigado.

Portanto, inequivocamente ilícito ingresso dos policiais militares na casa do preso.

Ora, a apreensão dos objetos que fornecem substrato ao juízo de materialidade do tráfico e da receptação foi derivado de uma diligência ilícita e nos termos do §1º do art. 157 do Código de Processo Penal não pode ser aceita.

A esse respeito é claro o comando constitucional inscrito no inciso LVI do art. 5º:

são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos

Não bastasse isso, ainda que superada esta questão (o que não se consegue sem um retrocesso civilizatório) não vejo em relação ao delito de tráfico elementos a indicar a finalidade comercial da droga encontrada, elemento subjetivo específico exigido pelo art. 33 da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, nos termos do inciso LXV da Constituição e do inciso I do art. 310 do Código de Processo Penal, declaro o flagrante ilegal, determinando o imediato relaxamento da prisão.

Consta da decisão que não recebeu a denúncia:

A mudança de posição do parquet em relação ao consentimento do pai é irrelevante, pois a denúncia identificada, ainda mais por alguém próximo do imputado, constitui sim justa causa para ingresso em domicílio. Afinal, caso a diligência mostre-se infrutífera, o denunciante pode ser responsabilizado civil e até criminalmente. Todavia, não se pode deixar de apontar que o fato de alguém ser o proprietário em nada influi na garantia constitucional, a qual não protege o imóvel, o bem patrimonial, mas a residência como espaço fundamental para o desenvolvimento da personalidade do cidadão. Trata-se, obviamente, de direito de caráter não patrimonial, razão pela qual o texto constitucional é claro em dizer a necessidade de consentimento do "morador", não do seu "proprietário". O mero proprietário não é titular do direito constitucionalmente protegido. Tanto que o imóvel desabitado ou abandonado não é objeto de proteção, conforme remansosa jurisprudência do STF. Agora, a situação de urgência/emergência apontada, com a devida vênia, é um esforço hercúleo (visto que não calcado nos relatos policiais) baseado em circunstâncias que não demonstram o risco de frustração da diligência caso se esperasse pelo mandado judicial (posição do Superior Tribunal de Justiça). A este respeito é sempre bom rememorar o voto-vista do Ministro Schietti Cruz, da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do RHC 83.501/SP (rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 06/03/2018, DJe 05/04/2018):

Sem embargo, vale lembrar que, se é verdade que o art. 5º, XI, da Constituição Federal, num primeiro momento, parece exigir a emergência da situação para autorizar o ingresso em domicílio alheio sem prévia autorização judicial – ao elencar hipóteses excepcionais como o flagrante delito, casos de desastre ou prestação de socorro –, também é certo que nem todo crime permanente denota essa emergência, consoante bem observa Celso Delmanto:

[...] o flagrante que constitui verdadeira emergência para que se admita a violação domiciliar a qualquer hora do dia ou da noite sem prévia autorização judicial. Seriam hipóteses, por exemplo, de flagrante de crimes permanentes como a extorsão mediante sequestro, em que há a necessidade de prestar-se socorro imediato à vítima que corre perigo de vida etc., o que não se verifica em casos de crimes permanentes como a simples posse de entorpecentes ou de armas ilegais. [...] Não obstante se possa alegar que esse entendimento poderia obstaculizar a ação policial, este é o preço que se paga por viver em um Estado Democrático de Direito, que deve tomar todas as medidas para restringir, ao máximo, a possibilidade de arbítrios e desmandos das autoridades policiais por mais bem intencionadas que possam elas estar. (Código Penal Comentado. 6. ed. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 324, destaquei).

Em julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o então Desembargador Geraldo Prado assim vociferou:

O ingresso não pode decorrer de um estado de ânimo do agente estatal no exercício do poder de polícia. Ao revés, é necessário que fique demonstrada a fundada – e não simplesmente íntima – suspeita de que um crime esteja sendo praticado no interior da casa em que se pretende ingressar e que o ingresso tenha justamente o propósito de evitar que esse crime se consuma. Se assim não fosse, seria permitido ingressar nas casas alheias, de forma aleatória, até encontrar substrato fático, consistente em flagrante delito, capaz de ensejar a formal instauração de procedimento investigatório criminal. Mais que isso, seria incentivar que a autoridade policial assim fizesse e, com a intenção de se livrar de uma eventual imputação de abuso de

autoridade, "encontrasse" à força o estado de flagrância no domicílio indevidamente violado. (TJRJ. Apelação Criminal 2009.050.07372, Rel. Des. Geraldo Prado, julgado em 17/12/2009).

É sobre estes motivos que a defesa tem a oportunidade de fazer, de forma diferida, o contraditório acerca da diligência invasiva, exercendo o controle devido sobre a atividade policial.

Já no HC 598.501/SP (julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021) o Ministro Schietti Cruz aprofundou suas considerações (grifos nossos):

2. O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

2.1. Somente o flagrante delito que traduza verdadeira urgência legítima o ingresso em domicílio alheio, como se infere da própria Lei de Drogas (L. 11.343/2006, art. 53, II) e da Lei 12.850/2013 (art. 8º), que autorizam o retardamento da atuação policial na investigação dos crimes de tráfico de entorpecentes, a denotar que nem sempre o caráter permanente do crime impõe sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar danos; é dizer, mesmo diante de situação de flagrância delitiva, a maior segurança e a melhor instrumentalização da investigação - e, no que interessa a este caso, a proteção do direito à inviolabilidade do domicílio - justificam o retardo da cessação da prática delitiva.

2.2. A autorização judicial para a busca domiciliar, mediante mandado, é o caminho mais acertado a tomar, de sorte a se evitarem situações que possam, a depender das circunstâncias, comprometer a licitude da prova e, por sua vez, ensejar possível responsabilização administrativa, civil e penal do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além, é claro, da anulação - amiúde irreversível - de todo o processo, em prejuízo da sociedade.

3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), a tese de que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). Em conclusão a seu voto, o relator salientou que a interpretação jurisprudencial sobre o tema precisa evoluir, de sorte a trazer mais segurança tanto para os indivíduos sujeitos a tal medida invasiva quanto para os policiais, que deixariam de assumir o risco de cometer crime de invasão de domicílio ou de abuso de autoridade, principalmente quando a diligência não tiver alcançado o resultado esperado.

De notar a citação do ministro à Gisela Wanderley, magistrada desse tribunal.

[A] situação de flagrante delito, em especial nos casos de crimes permanentes, não necessariamente configura uma hipótese de urgência, a qual justificaria o excepcional ingresso na residência a qualquer tempo e sem controle prévio de legalidade. Com efeito, especialmente em virtude da proliferação de tipos penais de perigo abstrato na legislação, diversas situações de flagrante delito não implicam perigo nem mesmo potencial a bem jurídico. Assim, é crucial notar que há crimes cuja situação de flagrância implica situação de urgência e crimes cuja situação de flagrância não implica situação de urgência. Nessa esteira, pode ser particularmente elucidativo o contraste entre os crimes de sequestro (CP, art. 148) e de posse de entorpecentes em depósito (Lei 11.343/2006, art. 33), ambos crimes permanentes passíveis de cometimento em ambiente domiciliar. No primeiro caso (sequestro), o dano ao bem jurídico tutelado pela norma incriminadora (liberdade individual) se prolonga ao longo da execução do crime e justifica a entrada

imediate no domicílio a fim de cessar a prática delitiva. No segundo caso (posse de entorpecentes em depósito), não se verifica uma situação de dano, nem de perigo concreto, nem de perigo potencial, configurada pela mera presença de substâncias entorpecentes no interior da residência. Não há situação de urgência, portanto, que dispense o controle prévio da legalidade da medida. Não por outra razão, a própria Lei 11.343/2006 (cf. art. 53, II) 9) autoriza o “flagrante diferido” na investigação dos crimes de tráfico de entorpecentes, exatamente porque se trata de crime cuja prática não desencadeia situação de dano ou de perigo concreto. Assim, como a prática delitiva não demanda a sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar dano, permite-se que, mesmo diante de situação de flagrância, a investigação seja diferida no tempo a fim de angariar elementos de informação mais robustos e abrangentes. É curioso notar, no ponto, que o flagrante diferido somente pode ser realizado com a devida autorização judicial prévia, acrescida da oitiva de membro do Ministério Público. Trata-se de importante previsão legal, que submete o acompanhamento policial diuturno das rotinas dos suspeitos a escrutínio judicial, evitando-se a banalização da devassa da vida privada, ao arrepio do disposto no inc. X do art. 5.º da CF/1988. Torna-se evidente, assim, que a situação de flagrância não apenas não constitui hipótese de obrigatoriedade da intervenção policial, como também não constitui hipótese impeditiva do controle judicial de validade da intervenção policial orientado à proteção dos direitos fundamentais dos suspeitos. Nesse contexto, é forçoso concluir que a situação de flagrância, diante dos atuais termos da legislação penal e processual penal vigente, não equivale a uma situação de urgência. Ao contrário, a própria legislação infraconstitucional indica a não coincidência entre flagrância e urgência ao permitir a postergação da prisão em flagrante em casos determinados, em que a melhor instrumentalização da investigação justifica o retardo na interrupção da prática delitiva. Assim, constata-se que a mera situação de flagrante delito, nos termos em que definida pela legislação infraconstitucional (CPP, art. 302 c/c 303), não é suficiente para justificar a excepcional dispensa de autorização judicial prévia para a prática de busca domiciliar, a qual se restringe apenas aos casos de urgência, nos quais se inviabiliza o controle prévio de validade do ato. No ponto, reitera-se que, em especial nos casos de crimes de perigo abstrato, que ora se disseminam na legislação pátria, a prática delitiva não implica perigo concreto ou dano ao bem jurídico que justifique a intervenção policial imediata. Assim, não há empecilho a que o policial requeira autorização judicial para a entrada forçada em domicílio. Nessa trilha, torna-se evidente que a presunção de urgência nos casos de flagrante delito não pode ser interpretada como absoluta, sob pena de se viabilizar o esvaziamento do direito fundamental à inviolabilidade domiciliar por meio da legislação penal infraconstitucional. (Liberdade e suspeição no Estado de Direito: o poder policial de abordar e revistar e o controle judicial de validade da busca pessoal. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade de Brasília, Brasília, 2017. Disponível em: [https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/24089/3/2017_GiselaAguiar Wanderley.pdf](https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/24089/3/2017_GiselaAguiar%20Wanderley.pdf). Acesso em: 4/10/2020.

Voltando ao caso.

Em primeiro lugar, a argumentação do Ministério Público não supre a ausência de razões declinadas pelos policiais responsáveis pela diligência.

É sobre estes motivos que a defesa tem a oportunidade de fazer, de forma diferida, o contraditório acerca da diligência invasiva, exercendo o controle devido sobre a atividade policial.

Trabalhar com justificativas novas, além de se distanciar da realidade, permite que a persecução penal desenvolva-se para, como se diz no jargão forense, “arredondar a ocorrência”, buscar, a posteriori, uma razão que torne justo aquilo que nasceu como arbitrário.

O STF, por ocasião do julgamento do Tema 280 da sua Repercussão Geral, já definiu que as razões a justificar o ingresso no domicílio devem ser anteriores ao ato. Os policiais já contam com a possibilidade de declinar tais razões posteriormente, quando ouvidos pela autoridade policial civil. Estender ao estado-acusação a

possibilidade de justificar o ato de forma inovadora por ocasião do oferecimento da denúncia implica transformar este controle da polícia a partir de parâmetros constitucionais (a chamada constitucionalização da atividade policial) em um exercício de retórica judicial.

O ato da polícia é um ato administrativo e como tal deve ser motivado desde o início, não podendo este requisito ser suprido posteriormente por outro órgão.

Mas ainda que se supere isso, os argumentos deduzidos pelo parquet são frágeis.

O fato de o bem ser de duas rodas, francamente, não é um motivo relevante, tampouco o descontentamento do pai ou a denúncia feita por este.

Levando a sério o argumento do Ministério Público, toda e qualquer denúncia sobre uma moto ensejaria autorização para ingresso em domicílio sem mandado. Obviamente que nenhum intérprete minimamente comprometido com o texto constitucional ofereceria adesão a tal tese. E o confronto com a citada orientação do STJ é nítido.

Ademais, a denúncia do pai à polícia, salvo melhor juízo, não era de conhecimento do imputado. Razão pela qual tampouco serve de justificativa para a diligência.

Mas, mais importante que tudo isso, é o silêncio da denúncia acerca da continuidade da diligência na residência do imputado.

Frisei por ocasião da análise do flagrante (sem grifos no original).

Ademais, ainda que se considere o ingresso inicial válido, após o encontro da moto indicada pelo informante identificado, não poderiam os policiais continuar a revistar o domicílio, a menos que declinassem "fundadas razões" para tal. Aliás, mesmo quando autorizados por mandado judicial, uma vez encontrado o objeto-alvo, como se depreende dos §§6º e 7º do art. 245 do Código de Processo Penal, cabe aos executores da medida fazer a apreensão e lavrar o auto circunstanciado, interrompendo, por óbvio, as buscas.

A razão disso é evidente.

Ainda que legítima a busca, ela não suspende os direitos do investigado, apenas abre uma exceção, justificada, no tempo e no espaço, circunscrita a uma finalidade prévia. De resto, o direito à inviolabilidade de domicílio continua valendo integralmente. O ingresso na casa de investigado mediante autorização judicial ou mediante fundadas razões do cometimento de crime não é permissivo para devassa na vida do investigado.

Ou seja, ainda que se considere legítima a diligência até o encontro da moto, o fato é que até esse momento da persecução penal nenhuma justificativa foi dada para a continuidade das buscas, as quais consistiram em devassa da intimidade do imputado.

A disciplina constitucional (art. 5º, inciso LVI) é inequívoca:

são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos

Como a diligência policial foi ilícita, ela não pode ser considerada uma causa justa para fundamentar uma acusação criminal.

Como tanto a prova da imputação da receptação, quanto a prova do tráfico não possuem outra fonte independente (art. 157, §1º, do Código de Processo Penal), é forçoso reconhecer não há condições para o exercício da ação por falta de justa causa.

Ante o exposto, REJEITO a denúncia oferecida contra Dhiego da Silvados Santos, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

De forma sucinta, o flagrante foi declarado ilegal por não haver no ingresso em domicílio dos policiais uma situação de urgência/ emergência, tal qual exige a jurisprudência dos tribunais superiores.

Na decisão que rejeitou a denúncia, diante da mudança de posição do parquet, outras

razões foram apontadas.

A primeira foi que a autorização por alguém diverso do morador não encontra amparo na autorização dada pelo texto constitucional ("ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador").

A segunda foi pela impossibilidade de suplementação por parte do MP acerca da fundamentação dos funcionários públicos responsáveis pela diligência invasiva.

Por fim, a completa ausência de fundamentação para a continuidade da diligência após o encontro do bem que se procurava.

As razões permanecem cabíveis ao caso.

Em juízo, o policial militar Coutinho relatou que o Senhor José apenas lhe disse que havia uma movimentação estranha no local, o que é absolutamente inferior ao padrão exigido pelo já citado Tema 280 da Repercussão Geral do STF, o qual adota, por analogia, o art. 240 do Código de Processo Penal. E neste dispositivo exige-se "fundadas razões" de que na residência encontre-se algo conforme as alíneas do §1º. E como vem se posicionando o STJ, a preferência é sempre pela busca com mandado, sendo cabível a diligência sem autorização judicial quando evidenciada a urgência no caso, o que em momento algum dos relatos policiais foi sequer alegada.

O policial militar Saggioratto, por sua vez, disse que as declarações suas na fase pré-processual a respeito da negativa do acusado relativa ao ingresso em domicílio derivaram de uma inferência feita pela autoridade policial, pois lhes perguntou se houve o consentimento do preso e disseram que não. Tomando isso por verdade, infere-se que até mesmo a autoridade policial reconheceu a ausência de consentimento no ato.

Digno de nota ainda o relato do Senhor José no sentido de que não mora no imóvel há 25 anos. E que o filho, ora acusado, vive em situação de rua, sendo que outras pessoas que fazem coisas erradas tomaram conta do imóvel. A partir disso, ou se conclui que a diligência foi lícita porque o imóvel não era moradia de ninguém, e aí seria inexorável a absolvição, pois o elemento usado para a imputação da autoria é justamente a posse do imóvel (nesse ponto vale ressaltar que o Senhor José, apesar de, segundo os policiais, ter se apresentado como proprietário do imóvel, em momento algum esteve sob suspeita da justiça – a revelar a pouca importância da propriedade registral para o caso), ou se conclui que a moradia era do acusado e, assim, as diligências foram ilícitas. A licitude da diligência e a imputação da autoria a partir da moradia não podem coexistir a partir do contexto colhido nos autos.

Aliás, o estado absolutamente degradante em que se encontrava a pessoa imputada torna duvidosa sua capacidade para ocultar o veículo e praticar a traficância. Os policiais em juízo disseram acreditar que as drogas eram para uso e que não conheciam o acusado como traficante e sequer tinham notícias dele nesta atividade espúria. A indicar que se as porções de cocaína fossem realmente dele, seriam para uso.

E a partir dos relatos do Senhor José a respeito da ocupação do imóvel e do estado em que os policiais disseram encontrar a pessoa imputada, é pouco crível que estivesse realmente ocultando uma moto. Aliás, agindo de uma forma muito diversa daquela habitualmente realizada pelos receptadores, a pessoa imputada, apesar da confusão mental, indicou o imóvel onde estariam os "proprietários" da moto, local onde os policiais encontraram a chave dela. A reforçar que sequer deveria saber da proveniência ilícita do bem.

Em reforço às razões já anteriormente expostas, e respeitando entendimentos em sentido oposto, a garantia de inviolabilidade de domicílio está inserida no capítulo "Dos direitos e deveres individuais e coletivos" e pela sua feição trata-se, nitidamente, de garantia individual. Tendo tal natureza não pode ser flexibilizada por ato de terceiro.

Veja, não se trata nem de um caso em que um morador autoriza o ingresso em desfavor de outro. A pessoa que autorizou a entrada sequer morador era.

Além disso, não se aceita, nos termos do entendimento do STF em precedente vinculante (RE 603.616, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe 10/05/2016. Tema 280 da Repercussão Geral), a justificativa de que

o sucesso da diligência a torna legítima. Isso porque, obviamente, somente as diligências frutíferas chegarão ao conhecimento do judiciário e a única forma de desincentivar comportamentos incompatíveis com a ordem jurídica é decretando a sua nulidade. É a posição do STF:

Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.

RE 603.616, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe 10/05/2016. Tema 280 da Repercussão Geral.

Quanto à análise das palavras do policiais é preciso estabelecer uma diferenciação. Em relação ao objeto da denúncia, eles possuem, em geral, o devido distanciamento e suas palavras ganham especial relevo; até porque são incumbidos pela sociedade para exercer nobre função de segurança pública. Todavia, em relação às circunstâncias que constituem justa causa para as diligências invasivas as suas palavras devem merecer um especial escrutínio em razão da extremo poder que concentram a respeito, como também porque em caso de eventual irregularidade poderão responder judicial e administrativamente.

É a orientação do STF no julgado citado citado. Com grifos nossos:

Entende-se que a exigência de um mandado judicial autorizando a interferência no domicílio é importante para evitar abusos e arbítrios. No entanto, em situações exigentes, “a ausência de mandado judicial prévio pode ser contrabalançada pela disponibilidade de um controle ex post factum”. Assim, as buscas sem autorização judicial deverão ser passíveis de rigoroso escrutínio a posteriori por magistrado – nesse sentido, Heino contra Finlândia (caso n. 56720/09), decisão de 15.2.2011; Smirnov contra Rússia (caso 71362/01), decisão de 7.6.2007.

O controle judicial da investigação criminal serve para compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública. Esse controle pode ser a priori – antes da adoção da medida que afeta direitos fundamentais – ou a posteriori – após a adoção da medida. No controle prévio, a adoção da medida deve ser precedida da expedição de uma ordem judicial. O juiz, terceiro imparcial, analisa a presença dos requisitos da medida e, se for o caso, autoriza sua realização.

No controle a posteriori, a legislação permite aos agentes da administração desde logo atuar, realizando a medida invasiva. Apenas depois de sua concretização, o terceiro imparcial verifica se os agentes da administração agiram de acordo com o direito, analisando se estavam presentes os pressupostos da medida e se sua execução foi conforme o direito.

O controle a posteriori pode ser adotado, mesmo em medidas invasivas, se houver razões suficientes para tanto.

É o que ocorre no caso da prisão em flagrante – art. 5º, LXI, da CF. Trata-se de exceção à exigência de prévia ordem escrita da autoridade judiciária para a prisão, fundada na urgência em fazer cessar a prática de crime e na evidência de sua autoria. No entanto, é indispensável o controle da medida a posteriori, mediante imediata comunicação ao juiz, que analisa a legalidade da prisão em flagrante – art. 5º, LXII, da CF.

RE 603.616, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe 10/05/2016. Tema 280 da Repercussão Geral.

Pelo STF, a propósito, não só deve haver o controle sobre a atividade policial, como também as suas próprias justificativas devem ser vistas com “especial escrutínio”.

O policial pode invocar o próprio testemunho para justificar a medida. Claro que o ingresso forçado baseado em fatos presenciados pelo próprio policial que realiza a busca coloca o agente público em uma posição de grande poder e, por isso mesmo, deve merecer especial escrutínio.

RE 603.616, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe 10/05/2016. Tema 280 da Repercussão Geral.

No sentido da preocupação com quais elementos podem ser usados como justificativa para as diligências invasivas é ilustrativo o voto-vista do Ministro Rogério Schietti Cruz no RHC 83.501/SP julgado pelo STJ:

Não se desconhece que, consoante afirmou o Ministro Gilmar Mendes por ocasião do julgamento do referido RE n. 603.616/RO, "A busca e apreensão domiciliar é uma medida invasiva, mas de grande valia para a repressão à prática de crimes e para a investigação criminal" (p. 10 do acórdão). Também não perco de vista que, não raro, é tênue a distinção dos limites circunstanciais entre a legitimidade da ação de ingresso e a afetação do direito à inviolabilidade de domicílio. No entanto, é de particular importância (re)pensar em que medida o ingresso na esfera domiciliar para apreensão de drogas em determinadas circunstâncias representa uma intervenção restritiva legítima do ponto de vista constitucional, e não uma violação do direito fundamental à inviolabilidade de domicílio. Isso porque a ausência de justificativas e de elementos seguros a autorizar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativamente à ocorrência de tráfico de drogas, pode acabar esvaziando o próprio direito à privacidade e à inviolabilidade de sua condição fundamental.

Além disso, ainda que se estivesse na posse de mandado judicial, uma vez encontrado o objeto perseguido (§§6º e 7º do art. 245 e art. 248, ambos do Código de Processo Penal) a procura deveria ser imediatamente encerrada (exceto, obviamente, se os agentes públicos estivessem diante de nova justa causa para continuar a revista). Ao continuidade da busca após o encontro do objeto perseguido deu-se sem razões adicionais, portanto, sem justa causa. Constituiu, portanto, a indesejada "pescaria probatória" ("fishing expedition").

É como decidiu o Superior Tribunal de Justiça em caso recente (com grifos nossos):

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E FALSA IDENTIDADE. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DESVIO DE FINALIDADE E FISHING EXPEDITION. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.
3. Por ocasião do julgamento do HC n. 598.051/SP (Rel. Ministro Rogério Schietti), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs nova e criteriosa abordagem sobre o controle do alegado consentimento do morador para o ingresso em seu domicílio por agentes estatais. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: a) Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de standard probatório para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito; b) O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da

obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada; c) O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação; d) A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato.

Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo; e) A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência.

4. Sobre a gravação audiovisual, o plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento dos Embargos de Declaração na Medida Cautelar da ADPF n. 635 ("ADPF das Favelas"), reconheceu a imprescindibilidade de tal forma de monitoração da atividade policial e determinou, entre outros, que "o Estado do Rio de Janeiro, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, instale equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes de segurança, com o posterior armazenamento digital dos respectivos arquivos".

5. Por se tratar de medida invasiva e que restringe sobremaneira o direito fundamental à intimidade, o ingresso em morada alheia deve se circunscrever apenas ao estritamente necessário para cumprir a finalidade da diligência, conforme se extrai da exegese do art. 248 do CPP, segundo o qual, "Em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência".

6. É ilícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso em domicílio, seja no cumprimento de mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, seja na hipótese de ingresso sem prévia autorização judicial, como ocorre em situação de flagrante delito. O agente responsável pela diligência deve sempre se ater aos limites do escopo - vinculado à justa causa - para o qual excepcionalmente se restringiu o direito fundamental à intimidade, ressalvada a possibilidade de encontro fortuito de provas.

7. Admitir a entrada na residência especificamente para efetuar uma prisão não significa conceder um salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (fishing expedition), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade.

8. Segundo Alexandre Morais da Rosa, "Fishing Expedition ou Pescaria Probatória é a procura especulativa, no ambiente físico ou digital, sem 'causa provável', alvo definido, finalidade tangível ou para além dos limites autorizados (desvio de finalidade), de elementos capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém. [É] a prática relativamente comum de se aproveitar dos espaços de exercício de poder para subverter a lógica das garantias constitucionais, vasculhando-se a intimidade, a vida privada, enfim, violando-se direitos fundamentais, para além dos limites legais. O termo se refere à incerteza própria das expedições de pesca, em que não se sabe, antecipadamente, se haverá peixe, nem os espécimes que podem ser fiscados, muito menos a quantidade" (ROSA, Alexandre Morais da, Guia do Processo Penal Estratégico: de acordo com a Teoria dos Jogos, 1ª ed., Santa Catarina: Emais, 2021, p. 389-390).

9. Sobre o desvio de finalidade no Direito Administrativo, Celso Antonio Bandeira de Mello ensina: "Em rigor, o princípio da finalidade não é uma decorrência do princípio da legalidade. É mais que isto: é uma inerência dele; está nele contido, pois corresponde à aplicação da lei tal qual é; ou seja, na conformidade de sua razão de ser, do objetivo em vista do qual foi editada. Por isso se pode dizer que tomar uma lei como suporte para a prática de ato desconforme com sua finalidade não é aplicar a lei; é desvirtuá-la; é burlar a lei sob pretexto de cumpri-la. Daí por que os atos incursos neste vício denominado 'desvio de poder' ou 'desvio de

finalidade' são nulos. Quem desatende ao fim legal desatende à própria lei" (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio, Curso de Direito Administrativo, 27 ed., São Paulo: Malheiros, 2010, p. 106).

10. No caso dos autos, o ingresso em domicílio foi amparado na possível prática de crime de falsa identidade, na existência de mandado de prisão e na suposta autorização da esposa do acusado para a realização das buscas.

10.1 O primeiro fundamento - crime de falsa identidade - não justificava a entrada na casa do réu, porque, no momento em que ingressaram no lar, os militares ainda não sabiam que o acusado havia fornecido anteriormente à guarnição os dados pessoais do seu irmão, o que somente depois veio a ser constatado. Não existia, portanto, situação fática, conhecida pelos policiais, a legitimar o ingresso domiciliar para efetuar-se a prisão do paciente por flagrante do crime de falsa identidade, porquanto nem sequer tinham os agentes públicos conhecimento da ocorrência de tal delito na ocasião.

10.2 No tocante ao segundo fundamento, releva notar que, além de não haver sido seguido o procedimento legal previsto no art. 293 do CPP, não se sabia - com segurança - se o réu estava na casa, visto que não fugiu da guarnição para dentro do imóvel com acompanhamento imediato em seu encalço; na verdade, o acusado tomou rumo ignorado, com notícia de que provavelmente estaria escondido dentro do cemitério, mas os agentes foram até a residência dele "colher mais informações".

10.3 Mesmo se admitida a possibilidade de ingresso no domicílio para captura do acusado - em cumprimento ao mandado de prisão ou até por eventual flagrante do crime de falsa identidade -, a partir das premissas teóricas acima fundadas, nota-se, com clareza, a ocorrência de desvirtuamento da finalidade no cumprimento do ato.

Isso porque os objetos ilícitos (drogas e uma munição calibre .32) foram apreendidos no chão de um dos quartos, dentro de uma caixa de papelão, a evidenciar que não houve mero encontro fortuito enquanto se procurava pelo réu - certamente portador de dimensões físicas muito superiores às do referido recipiente -, mas sim verdadeira pescaria probatória dentro do lar, totalmente desvinculada da finalidade de apenas capturar o paciente.

10.4 Por fim, quanto ao último fundamento, as regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que a esposa do paciente - adolescente de apenas 16 anos de idade - teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso no domicílio do casal, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, conseqüentemente, a formação de prova incriminatória em desfavor de seu cônjuge. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento, quer por escrito, quer por testemunhas, quer, ainda e especialmente, por registro de áudio-vídeo.

10.5 A descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em violação da norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela derivados, porque decorrentes diretamente dessa diligência policial.

É preciso ressaltar, contudo, que a condenação pelo crime do art. 307 do CP (falsa identidade) não é atingida pela declaração de ilicitude das provas colhidas a partir da invasão de domicílio, eis que a prática do delito, ao que consta, foi anterior ao ingresso dos agentes no lar do acusado.

11. Ordem parcialmente concedida para reconhecer a ilicitude das provas obtidas a partir da violação do domicílio do acusado, bem como de todas as que delas decorreram, e, por conseguinte, absolvê-lo das imputações relativas aos crimes do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 14 da Lei n. 10.826/2003.

HC 663055/MT, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/03/2022, DJe 31/03/2022.

Portanto, com a devida vênia aos entendimentos em contrário, as provas colhidas pela acusação foram obtidas por meios ilícitos, as quais são inadmissíveis nos termos do inciso LVI do art. 5º da Constituição.

Em relação ao estado de liberdade da pessoa imputada tendo a questão sido analisada pelas instâncias superiores a partir de circunstâncias de fato e de direito próximas àquelas analisadas nesta sentença, deixo de me manifestar, devendo eventuais pedidos ser direcionados a tais instâncias.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido condenatório para ABSOLVER DHIEGO DA SILVA DOS SANTOS das acusações a ele imputadas na denúncia nos termos do inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06 e Comunicado CG 2225/18, determino a destruição de eventuais amostras de entorpecentes guardadas para contraprova.

Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as anotações de praxe.

Porto Ferreira, 14 de junho de 2022.

Valdemar Bragheto Junqueira - Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA